

1500126-07.2022.8.26.0583

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Magistrado: Cibele Carrasco Rainho Novo

Comarca: Presidente Prudente

Foro: Foro de Presidente Prudente

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/09/2022

... REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE NÃO DECLINARAM OBJETIVA E CONCRETAMENTE A ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DO ACUSADO PEDRO PARA A PRÁTICA DA NARCOTRAFICÂNCIA. ÔNUS QUE SE IMPÕE NO SISTEMA ACUSATÓRIO. INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Presidente Prudente

Foro de Presidente Prudente

2ª Vara Criminal

Avenida Coronel José Soares Marcondes, 2201, Presidente Prudente - SP - cep 19013-050

1500126-07.2022.8.26.0583 - lauda

SENTENÇA

CONCLUSÃO:

Em 29 de agosto de 2022, faço a conclusão destes autos à Exma. Sra. Dra. CIBELE CARRASCO RAINHO NOVO, MMª. Juíza de Direito Titular. Eu, Assistente Judiciário, digitei.

Processo nº:

1500126-07.2022.8.26.0583

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JEBECA BALVIN CALATAYUD e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Cibele Carrasco Rainho Novo

VISTOS.

JEBECA BALVIN CALATAYUD, qualificada nos autos (fls. 41), foi denunciada pela prática dos delitos tipificados nos artigos 33, "caput", c.c. o artigo 40, inciso V, e 35, "caput", todos da Lei nº 11.343/2006, na forma do artigo 69 do Código Penal; e ALEXSSANDRO RAMOS, qualificado nos autos (fls. 137), foi denunciado pela prática dos delitos tipificados nos artigos 33, "caput", c.c. o artigo 40, inciso V, e 35, "caput", todos da Lei nº 11.343/2006, bem como, no artigo 307 do Código Penal, em concurso material de crimes, porque, segundo narrativa contida na peça acusatória (fls. 03/06):

a) no dia 07 de fevereiro de 2022, por volta das 17h15min, na rodovia SP 270, 574, área rural, na cidade de Álvares Machado, nesta comarca de Presidente Prudente, JEBECA BALVIN CALATAYUD e ALEXSSANDRO RAMOS, juntos e com unidade de propósitos, traziam consigo e transportavam, sem licença da autoridade competente e em desacordo com determinação legal, 3.960 gramas de cocaína, acondicionadas em 04 tijolos, substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, classificada como droga alucinógena e despersonalizante;

b) em datas não identificadas, mas anteriormente ao dia 07 de fevereiro de 2022, nesta comarca e no Estado do Mato Grosso do Sul, JEBECA BALVIN CALATAYUD e ALEXSSANDRO RAMOS, em concurso com outros indivíduos não identificados nos autos, associaram-se com o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico de drogas;

c) no dia 07 de fevereiro de 2022, por volta das 17h15min, na rodovia SP 270, nº 574, área rural, na cidade de Álvares Machado, nesta comarca de Presidente Prudente, ALEXSSANDRO RAMOS atribuiu-se falsa identidade, fornecendo o nome fictício de Guillermo Mosciaro Ramos, com o fim de obter vantagem em proveito próprio.

Durante a fase de inquérito, providenciou-se a confecção e juntada do Auto de Prisão em Flagrante (fls. 07/08), Termos de depoimentos de testemunhas (fls. 09/10 e 11) e de interrogatórios (fls. 12 e 13), Boletins de Ocorrência (fls. 14/19 e 20/21), Auto de Exibição/Apreensão (fls. 22/23), fotografias das substâncias entorpecentes apreendidas (fls. 24/27), Certidão de Movimentos Migratórios (fls. 33/34), Laudo de Constatação (fls. 35/37), Solicitação de Legitimação (fls. 54/55 - Alexssandro), Pesquisa SSP-IIRGD (fls. 56/58), Pesquisa SIVEC (fls. 65 e 68), Pesquisa Fonética (fls. 66) e Certidão Estadual de Distribuições Criminais (fls. 67 e 69).

Realizou-se Audiência de Custódia (Termo a fls. 76/79), ocasião em que houve a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, com a expedição dos respectivos mandados (fls. 84/85 e 86/87), devidamente cumpridos (fls. 89/90 e 91/92), sobreindo aos autos Exame Químico-Toxicológico - Laudo Definitivo (fls. 124/126), Laudo Pericial referente aos objetos apreendidos (fls. 127/132) e Relatório Final do Inquérito Policial (sob nº 2035382-78.2022.090202 - fls. 133/136).

Houve oferecimento da denúncia (fls. 03/06), seguindo-se da juntada do Laudo Pericial atinente ao aparelho celular apreendido (fls. 167/172) e da notificação dos acusados (fls. 174 e 176).

Após a juntada da Folha de Antecedentes (fls. 177/179) e Certidão Estadual de Distribuições Criminais (fls. 180/181), a denunciada Jebeca, por seu nobre Defensor constituído (procuração a fls. 193), deduziu pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar (fls. 194/202), o qual, após a manifestação do Órgão Ministerial (fls. 211/227), restou indeferido (fls. 233/236).

Na sequência, por meio de Defensor Público, o acusado Alexssandro ofertou defesa prévia (fls. 228/232), bem como, a acusada Jebeca (fls. 250/266), tendo a peça acusatória, após a manifestação do Ministério Público (fls. 274 e 277/278), sido recebida em 04.05.2022 (fls. 279/281), ocasião em que houve a análise e manutenção da prisão preventiva dos réus, nos termos do artigo 316, §único do CPP, bem como, o indeferimento do pedido de liberdade provisória deduzido pela Defesa.

Após a citação dos acusados (fls. 307 e 311), houve a interposição do Habeas Corpus nº 2096071-64.2022.8.26.0000 (fls. 312), cujo pedido liminar restou indeferido (fls. 314/315), bem como, a solicitação de informação (fls. 313), a qual foi devidamente prestada (fls. 317/328).

Realizou-se audiência de instrução, debates e julgamento (Termo a fls. 335/336),

procedendo-se, por gravação audiovisual, à inquirição de três testemunhas, e ao ato de interrogatório dos acusados.

Houve nova análise e manutenção da prisão preventiva dos réus, nos termos do artigo 316, § único do CPP (fls. 342/343), seguindo-se da juntada de Folhas de Antecedentes (fls. 347/349 e 352/353) e Certidões de Distribuições Criminais (fls. 350/351 e 354/355).

O Ministério Público, em memoriais finais (fls. 359/367), pugnou pela condenação dos acusados, nos termos da denúncia e, no que tange a dosimetria da pena, pela aplicação da pena base acima do mínimo legal, pela incidência da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso V da Lei 11.343/06, pelo estabelecimento do regime fechado, terminando por opor-se à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

A Defesa da ré Jebeca Balvin Calatayud (fls. 373/390), por sua vez, aduzindo insuficiência probatória, pleiteou a sua absolvição, nos termos do artigo 386, incisos IV, V e VII do Código de Processo Penal, e, em caso de condenação, a fixação da pena base no mínimo legal, a incidência da atenuante do artigo 33, § 4º da Lei 11.343/2006, a fixação do regime mais brando, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, e a concessão do direito de recorrer em liberdade.

A Defesa do réu Alexssandro Ramos (fls. 392/409), por sua vez, sustentando as teses de insuficiência de provas, atipicidade das condutas, crime impossível e ausência de dolo específico, requereu a sua absolvição, nos termos do artigo 386, incisos VII ou III do CPP, e, em caso de eventual condenação, a fixação da pena base no mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da confissão, a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado, em seu patamar máximo, o estabelecimento do regime inicial aberto, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, e a concessão do direito de recorrer em liberdade.

É a síntese do necessário.

Passo a fundamentar e decidir.

Constato que o processo está em ordem, inexistindo irregularidade ou nulidade a sanar e, estando presentes as condições da ação penal e os pressupostos processuais, imperioso o julgamento do mérito.

E no mérito, à vista do Auto de Prisão em Flagrante (fls. 07/08), Termos de depoimentos de testemunhas (fls. 09/10 e 11) e de interrogatórios (fls. 12 e 13), Boletins de Ocorrência (fls. 14/19 e 20/21), Auto de Exibição/Apreensão (fls. 22/23), fotografias das substâncias entorpecentes apreendidas (fls. 24/27), Certidão de Movimentos Migratórios (fls. 33/34), Laudo de Constatação (fls. 35/37), Solicitação de Legitimação (fls. 54/55 – Alexssandro), Exame Químico-Toxicológico – Laudo Definitivo (fls. 124/126), Laudo Pericial referente aos objetos apreendidos (fls. 127/132) e prova oral (fls. 335/336), colhida sob o contraditório, concluo que a pretensão acusatória comporta parcial acolhimento, impondo-se a condenação de ambos os acusados pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, e, ainda, a condenação do acusado Alexssandro pela prática do delito tipificado no artigo 307 do Código Penal, afastando-se, em relação a ambos os acusados, a pretensão acusatória quanto ao delito disposto no artigo 35, caput, da Lei nº 11.343/06.

Vejamos.

Por primeiro, incontroverso nos autos, à vista do Laudo de Exame Químico-Toxicológico elaborado (fls. 124/126), tanto a natureza entorpecente das

substâncias apreendidas (Auto de Exibição e Apreensão a fls. 22/23), uma vez que "...DETECTADA presença da substância COCAÍNA", quanto as suas quantidades ("Massa Líquida: 1985 grama(s) e 2035 grama(s)").

Por segundo, no que tange à propriedade e destinação da aludida droga, diante das provas colhidas e circunstâncias dos fatos, evidencia-se que esta pertencia aos réus e se destinava ao tráfico ilícito de entorpecentes, figura prevista no artigo 33, "caput" da Lei nº 11.343/06.

Isto porque, em harmonia com o depoimento prestado na fase policial (fls. 09/10), a testemunha Marcelo Ferreira da Silva, policial militar, inquirida em Juízo (fls. 335/336), narrou que, na data dos fatos, estavam em uma operação de fiscalização tática de policiamento rodoviário, oportunidade em que abordaram um ônibus da empresa "Andorinha", com itinerário Campo Grande a Rio de Janeiro, e realizaram fiscalização no compartimento de passageiros e na fiscalização do coletivo, sendo que, em dado momento, perceberam os acusados desconfortáveis com a presença policial, e, após se dirigirem até eles, os quais estavam sentados nas poltronas de números trinta e nove e quarenta, fizeram a fiscalização e, nas duas bagagens do casal (uma preta e uma azul), identificadas com tickets de passagem (com suas numerações respectivas) e controle do motorista, que estavam sob suas cabeças, encontraram 04 (quatro) tijolos de drogas, aparentando ser pasta base de cocaína, distribuídos três em uma maleta e um em outra.

Narrou a testemunha policial, ainda, que, de pronto, os acusados assumiram a propriedade das bagagens, sendo que Alexssandro, que na ocasião se apresentou como Guillermo, assumiu a responsabilidade da droga, alegando que foi contratado por uma pessoa no terminal rodoviário de Corumbá para levar a droga até São Paulo, sendo que a mesma pessoa que o contratou em Corumbá faria contato com ele ao chegar no terminal rodoviário da Barra Funda, indicando a pessoa para ele entregar a droga, bem como, que, pelo serviço, receberia duzentos dólares por tijolo, valor este que seria pago quando regressasse à Corumbá.

Esclareceu o policial, também, que os acusados, os quais se apresentaram como marido e mulher e tinham uma criança de colo, foram conduzidos para Delegacia de polícia, ocasião em que, após pesquisa mais aprofundada, com exame das digitais, identificaram o acusado como Alexssandro, apurando que o documento por ele apresentado, com nome de Guillermo, era falso, e, em diligência, constataram que a acusada Jebeca já havia sido deportada em outra ocasião, tendo sido por ela informado que Alexssandro e Guillermo eram as mesmas pessoas. Elucidou, por fim, que a acusada, a respeito do entorpecente, demonstrou muito nervosismo, no entanto, disse que não sabia, tendo o acusado, na ocasião, informando que a responsabilidade era dele, que ele era o responsável pelo transporte da droga.

A testemunha Leonardo de Castro Gusman, policial civil, em Juízo (fls. 335/336), contou que, na data dos fatos, estava de plantão na Delegacia quando a Polícia Rodoviária apresentou a ocorrência do flagrante de tráfico de drogas, oportunidade em que o acusado se apresentou como Guillermo Mosciaro Ramos, portando um documento nesse sentido, todavia, a Polícia Civil adota o procedimento, em caso de dúvida de documento, de encaminhar via "Lead", termo usado dentro da própria Polícia de um sistema policial com o IIRGD, e, quando estava praticamente finalizado o flagrante, receberam a resposta do IIRGD, no sentido de que, de acordo com as digitais colhidas, não se trata da pessoa informada, mas sim de Alexssandro Ramos.

Informou o policial civil, ainda, que as informações apresentadas pelos acusados não coincidiam, pois informavam locais diversos de nascimento do acusado, razão pela qual começaram a desconfiar, tendo sido constatado, em relação ao acusado, que houve um flagrante de tráfico de drogas, em Presidente Epitácio, no final de 2019.

A testemunha Alexandre Castelaní Cardoso, policial militar, durante sua inquirição

(fls. 335/336), narrou que estava de serviço com seu parceiro de equipe, Cabo Marcelo, fiscalizando o ônibus de linha interestadual, que fazia itinerário Campo Grande/Rio de Janeiro (capital), ocasião em que, durante a vistoria e entrevista aos ocupantes do coletivo, os acusados (casal de bolivianos) apresentaram nervosismo exacerbado com a presença policial, razão pela qual foram indagados a respeito da origem e destino da viagem. Ato contínuo, ao realizarem uma vistoria em seus pertences, localizaram, em duas bolsas, quatro tabletes da droga conhecida como cocaína (pasta base), sendo que três estavam em uma bolsa e uma na outra bolsa, todas elas devidamente etiquetadas em nome dos dois passageiros (casal), que tinha uma criancinha de colo.

Elucidou referida testemunha, ademais, que o acusado alegou que pegou a droga em Corumbá e que ganharia duzentos dólares por peça (oitocentos dólares no total) quando retornasse, ressaltando que as bagagens estavam em posse dos acusados, na parte do salão de passageiros, inclusive, em uma das bagagens, a qual estava com Jebeca, havia, junto das drogas, alguns itens da criança, como fraude e roupas.

Por sua vez, a acusada Jebeca Balvin Calatayud, interrogada em Juízo (fls. 335/336), negou a prática dos crimes que lhes são imputados, elucidando que, apesar de parte dos entorpecentes apreendidos estarem em sua mala, não tinha conhecimento a respeito, pois quem pegou as malas e as colocou no ônibus foi seu marido, e como tinha uma bolsinha separada, com os pertencentes do seu filho, não precisou abrir sua bolsa durante a viagem de aproximadamente oito horas, tendo negado ter ficado nervosa durante a abordagem, elucidando, ainda, que viajavam para a residência de sua irmã, na cidade de São Paulo.

De seu turno, o acusado Alexssandro Ramos, durante seu interrogatório judicial (fls. 335/336), negou a prática do crime de falsa identidade, alegando, em confusa narrativa, que ao ser batizado na igreja, aparentemente na Bolívia, sua mãe cometeu um erro e trocou o nome, colocando Guillermo Mosciaro Ramos. De outro lado, confessou a prática do crime de tráfico de drogas, elucidando que um conhecido lhe ofereceu o "trabalho", tendo pegado a droga no mesmo dia em que embarcou, na rodoviária de Corumbá, enfatizando que sua esposa não sabia e não presenciou o momento em que conversava com a pessoa com quem pegou a droga.

Nesse quadro, é de se ver que, além da confissão do acusado (fls. 335/336) e da apreensão dos entorpecentes (Auto a fls. 22/23), não obstante a acusada ter informado que estava tranquila no momento da fiscalização, os milicianos, acostumados com tal situação, que é vivenciada cotidianamente, relataram, em seus depoimentos harmônicos, que os acusados, no momento da fiscalização, estavam desconfortáveis e apresentaram nervosismo exacerbado, tudo a indicar que ambos tinham conhecimento do entorpecente nas bagagens.

Além disso, de acordo com todo o conjunto probatório (B.O. a fls. 16: "foram localizadas duas mochilas, uma na cor preta e outra na cor azul, esta última de marca "Adidas", sendo localizados 4 "tijolos" divididos, 3 na mala preta e 1 na mala azul, contendo substância amarelada, aparentando pasta base de cocaína."); "as bagagens acima mencionadas estavam devidamente etiquetadas pela empresa de transporte "Andorinha", sob os números 440333 correspondente a mochila preta e a 440332 corresponde a mochila azul de marca "Adidas", conforme "CUPOM DE EMBARQUE DE CONTROLE DE BAGAGENS" ora apreendidos.") e, especialmente, o próprio depoimento da acusada em Juízo (fls. 335/336), vislumbra-se que parte do entorpecente apreendido estava em sua mala.

Outrossim, é possível observar diversas contradições nas narrativas do casal, principalmente no que tange ao motivo da viagem, uma vez que a acusada relatou que iriam até a residência de sua irmã, na cidade de São Paulo, passar alguns dias (uma semana; pensavam em morar em São Paulo), e que, no dia seguinte em que sua irmã conversou com seu esposo e ele aceitou, já viajavam rumo à São Paulo, todavia, o

acusado, de forma diversa, contou que no mesmo dia em que conversou com seu amigo sobre o “trabalho” (tráfico de drogas), chamou sua esposa para ir para São Paulo na casa de sua irmã para trabalharem lá, sendo que não tinham prazo para voltar.

Afora isso, imperioso pontuar que, ainda em Juízo, a acusada afirmou, enfaticamente, que seu companheiro (acusado) trabalhava em uma empresa na Bolívia, com carteira assinada, e que havia um ônibus que o buscava em Corumbá e o levava para o serviço, afirmando, ainda, que lhe foi concedida uma permissão de folga de duas semanas, enquanto o denunciado, de forma totalmente diversa, informou que trabalhava, há aproximadamente três ou quatro anos, na cidade de Corumbá, como moto táxi, de forma autônoma (conta própria), inclusive tinha uma motocicleta.

Ademais, a versão apresentada pelos acusados, no sentido que estavam viajando para casa da irmã de Jebeça, não restou alicerçada em nenhum elemento probatório, ou seja, inexiste nos autos qualquer documento ou testemunho que comprove a veracidade da narrativa apresentada, a qual, frise-se, só fora apresentada em Juízo, nada tendo nesse sentido sido dito, nem para os policiais que realizaram a abordagem, nem para a Autoridade Policial quando inquiridos (fls. 12 e 13) - oportunidade em que, ao invés de esclarecerem os fatos, optaram pelo silêncio -, conduta que, obviamente, traz total descrédito à inovatória explanação.

Além do mais, e não menos importante, é de se ver que o documento apreendido com o acusado (Auto a fls. 22/23; cópia a fls. 131 - “CÉDULA DE IDENTIDAD”), em que consta nome diferente do qual fora identificado, foi emitido em 04.02.2022 (“Emitida el 4 de Febrero de 2022”), três dias antes da data do crime (data dos fatos: 07.02.2022), circunstância a indicar, pois, que, diferente do alegado pelos acusados, a viagem fora planejada com antecedência, tanto que acusado providenciou o referido documento para utilizar durante sua empreitada criminosa.

Por fim, ainda em relação crime de tráfico, à vista das circunstâncias que permeiam o crime, é possível concluir, ao contrário do arguido pelos réus, que referida viagem seria exclusivamente para a prática do ilícito e que voltariam, logo após a entrega do entorpecente, para o local de origem, posto que, além de levarem apenas duas bagagens (mais uma bolsinha), presumivelmente pequenas, já que estavam com os acusados e não no compartimento próprio de bagagens (lateral externa do veículo), diante do tamanho dos tablets apreendidos, verifica-se que estes ocupavam grande parte dos espaços das malas (fotos a fls. 24/27), ou seja, não levavam roupas suficiente para se estabelecerem em São Paulo pelo período informado, bem como, não fora apreendido dinheiro em posse dos acusados, sendo plenamente possível concluir que, com a entrega do entorpecente, receberiam uma passagem de volta para Corumbá.

De outro lado, não restou demonstrado a existência de uma associação entre os acusados, com as características de estabilidade e permanência, para o fim de praticar o tráfico ilícito de entorpecentes.

Observe-se que, não obstante os acusados viajarem juntos, temerário se mostra concluir pela existência de vínculo associativo entre eles, pois não há nos autos elementos robustos a demonstrar o liame subjetivo necessário para caracterização do delito em apreço, mas, repita-se, apenas a circunstância de estarem juntos, a qual, isoladamente, e tratando-se de um casal, não é apta para demonstrar a caracterização de uma associação estável e permanente.

A propósito do tema tratado, transcrevo ementa de recente julgamento proferido pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE NÃO DECLINARAM OBJETIVA E CONCRETAMENTE A ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DO ACUSADO PEDRO PARA A PRÁTICA DA NARCOTRAFICÂNCIA. ÔNUS QUE SE IMPÕE NO SISTEMA

ACUSATÓRIO. INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4.º, DA LEI DE DROGAS. CABIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O delito de associação para o tráfico somente se configura quando evidenciado o dolo de se associar de forma estável e permanente, o que não ficou evidenciado nos autos com relação ao Acusado PEDRO. 2. Quanto ao pedido de retorno dos autos para análise da incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4.º, da Lei de Drogas pelo Tribunal de origem, cumpre salientar que, no caso, o exame da sentença e do acórdão impugnado permitiu a readequação integral das penas. 3. Agravo desprovido." (negritei)
(AgRg no HC n. 614.568/RJ, relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 14/3/2022).

A fim de corroborar o exposto, transcrevo ementas de recentes julgamentos proferidos pelo Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, com destaque:

"Apelação. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Arts. 33, caput, e 35, ambos da Lei nº 11.343/06. Sentença que absolveu todos os réus da prática de associação para o tráfico e desclassificou as condutas de RAFAEL e SILVIO para o disposto no art. 28 da referida lei. Insurgência ministerial. Ausência de provas de autoria. Circunstâncias do flagrante que indicam ser plausível a tese de RAFAEL e SILVIO, no sentido de serem meros usuários de entorpecentes – Pedido não acolhido. Associação para o tráfico não comprovada de forma cabal. Vigência do princípio do in dubio pro reo – Pleito não acolhido. Recurso não provido."
(Apelação Criminal 1500963-97.2020.8.26.0594; Relator (a): REINALDO CINTRA; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 30/07/2022).

"TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PRELIMINAR – Recurso em liberdade. Impossibilidade. Presentes os requisitos da prisão preventiva – Rejeição. MÉRITO – Configuração. Materialidade e autoria comprovadas. Confissão de Luiz corroborada pelos depoimentos dos policiais em harmonia com o conjunto probatório. Negativa de Fernando isolada – Apreensão de expressiva quantidade e variedade de drogas (27,300 quilogramas de "maconha", 6,86g da mesma substância; 425,52g de "cocaína" e 94,61g do mesmo produto), além de expressiva quantia em dinheiro, celulares e petrechos – Desclassificação para uso próprio. Impossibilidade – Condenações mantidas. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – Absolvição por insuficiência de provas. 'Non liquet'. Não demonstrado o necessário vínculo estável entre os réus. Concurso facultativo de agentes. Absolvição que se impõe. PENAS E REGIME DE CUMPRIMENTO – Bases fixadas acima dos patamares. Expressiva quantidade e variedade de drogas. Acréscimo de 1/2 para Luiz e 3/5 para Fernando, considerando, quanto a este, ainda, os maus antecedentes – Confissão de Luiz. Redução de 1/6 – Impossibilidade do reconhecimento da causa de diminuição do artigo 41 da Lei de Drogas. Inviável o redutor do § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 – Regime inicial fechado. Detração penal. Indireta progressão de regime. Necessidade de análise dos requisitos objetivo e subjetivo. Competência do Juízo das Execuções – Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, art. 44, I e III) – Apelo provido em parte para absolver os apelantes do artigo 35 da Lei nº 11.343/06 (CPP, 386, VII) e, via de consequência, reduzir as penas."
(Apelação Criminal 1502838-33.2021.8.26.0347; Relator (a): GILBERTO FERREIRA DA CRUZ; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 29/07/2022).

Outrossim, de todo pertinente a transcrição da argumentação exposta no voto do eminente Relator Gilberto Ferreira da Cruz, nos autos da Apelação supramencionada (nº 1502838-33.2021.8.26.0347):

"Com efeito, a Lei n. 11.343/2006, ao tipificar a associação para o tráfico (artigo 35), gerou crime plurissubjetivo, de concurso necessário, cuja configuração exige vínculo estável e permanente entre os membros associados, de modo que a simples reunião esporádica de agentes não se confunde com as elementares típicas do crime

de associação.”

Por outro lado, resta configurado o crime de falsa identidade (artigo 307 do CP) praticado pelo acusado Alexssandro, pois, tanto para os policiais militares que o abordaram, como para a Autoridade Policial competente, se identificou como Guillermo Mosciaro Ramos, só sendo possível apurar sua real identidade, dada a argúcia dos dedicados agentes, após o ato de legitimação, realizado através da colheita das impressões digitais (“Solicitação de Legitimação” a fls. 54/55).

Nesse contexto, não merece prosperar a tese de “não produzir prova contra si mesmo” arguida pela Defesa (fls. 392/409), uma vez que tal garantia não prevalece no momento de qualificação do interrogatório, seja ele em Juízo, ou em sede policial, sendo certo que, no presente caso, o acusado apresentou falsa identidade na ocasião de seu interrogatório policial (Termo a fls. 13).

Aliás, imperioso se faz a transcrição, na íntegra, do teor dos ensinamentos do doutrinador GUILHERME DE SOUZA NUCCI, em sua obra “Código Penal Comentado”, 10ª edição, Ed. Revista dos Tribunais, 2010, (pág. 1.086), os quais foram parcialmente lançados pela Defesa (fls. 400), in verbis:

“Autodefesa: não é infração penal a conduta do agente que se atribui falsa identidade para escapar da ação policial, evitando sua prisão. Está, em verdade, buscando fugir ao cerceamento de sua liberdade. Ora, se a lei permite que a pessoa já presa possa fugir, sem emprego de violência, considerando isso fato atípico, é natural que a atribuição de falsa identidade para atingir o mesmo fim também não possa ser assim considerada. Não abrange, no entanto, o momento de qualificação, seja na polícia, seja em juízo, pois o direito de silenciar ou mentir que possui o acusado não envolve essa fase do interrogatório.”
(negritei)

Ademais, não há de se falar em crime impossível, tampouco em ausência de dolo específico, uma vez que, diferente do alegado pela Defesa em memoriais finais (fls. 392/409), a mentira do réu não era “absolutamente ineficaz para atingimento da vantagem visada”, tendo sido descoberta, exclusivamente, em razão da estruturação da honrosa Polícia Civil do Estado, que possuía em seus bancos de dados (Sistema LEAD – fls. 54/55) as impressões digitais do acusado, somado ao empenho e perspicácia dos policiais, que, de pronto, desconfiaram da informação apresentada.

Além disso, também não é de se prosperar a tese de ausência de dolo específico para obtenção de vantagem, para si ou para outrem, ou de causar dano a outrem, pois, de forma cristalina, constata-se que a intenção do acusado era evitar que a autoridade tomasse conhecimento a respeito de condenação anterior recente, também pelo crime de tráfico de drogas (Certidão a fls. 350/351 – Processo nº 1501344-90.2019.8.26.0481), o que, por óbvio, seria sopesado (como, de fato, foi) para eventual soltura.

Assim sendo, demonstradas, com robustez, a materialidade e autoria delitivas, e ausentes excludentes de ilicitude e culpabilidade, de rigor se impõe a condenação dos réus Alexssandro e Jebeca pela prática do crime previsto no artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/06, bem como, a condenação do acusado Alexssandro pela prática do delito tipificado no artigo 307 do Código Penal.

Passo, pois, a dosimetria das penas, observando o sistema trifásico de fixação (art. 68 do Código Penal).

a) Ré Jebeca Balvin Calatayud:

Em consonância com os artigos 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei nº 11.343/06, observo que, apesar da ré ser primária e não ostentar qualquer condenação criminal,

apresenta culpabilidade acentuada (entendida como o grau de reprovabilidade de sua conduta), pois transportava consigo uma significativa carga de drogas ilícitas, que, além de proporcionar lucro vultuoso ao grupo criminoso articulador, elevando o seu poder econômico para a prática de outros crimes, fomenta a prática de outros delitos patrimoniais, notadamente os mais graves, causando, ainda, danos irreparáveis para diversas famílias, vítimas do vício nefasto proporcionado pela disseminação descontrolada de entorpecentes ilícitos.

Nesse raciocínio, fixo a pena base em patamar superior ao mínimo, aplicando-lhe a majoração de 1/6 (um sexto), ou seja, em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Por falta de elementos sobre a capacidade financeira da ré, o valor unitário do dia-multa deve ser fixado no mínimo legal.

Na segunda etapa da dosagem, verifico que inexistem circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Na terceira fase do cálculo, presente a causa de aumento capitulada no art. 40, inciso V da Lei nº 11.343/06, haja vista o tráfico ter ocorrido entre os Estrados da Federação (Mato Grosso do Sul e São Paulo), elevam-se as penas em 1/6 (um sexto), passando-as para 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multas.

Imperioso, por outro lado, o reconhecimento da causa de diminuição de pena capitulada no artigo 33, § 4º, Lei nº 11.343/06, posto que a ré não ostenta qualquer condenação criminal e não há prova de que integre organização criminosa, tampouco de que se dedique à atividades ilícitas.

De outro vértice, não é o caso de se aplicar a fração máxima de redução, haja vista, além do efeito deletério, a significativa quantidade do entorpecente apreendido (cocaína).

Nesse sentido:

“Na falta de indicação pelo legislador de balizas para o quantum de redução, a natureza e a quantidade de droga apreendida, assim como as demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem ser utilizadas na definição do patamar de redução ou, até mesmo, para impedir a aplicação da minorante quando evidenciarem a dedicação do agente ao tráfico de entorpecentes. Precedentes”.
(STJ; HC 364113/SP; Quinta Turma; Ministro Ribeiro Dantas; j. 04.10.2016).”

Nesse raciocínio, tais elementos determinam a redução intermediária da pena em 1/2 (metade), passando-a para 03 (três) anos, 04 (quatro) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e 340 (trezentos e quarenta) dias-multa.

Por sua vez, quanto ao regime prisional, tendo em vista o quantum da pena imposta e a recente decisão do C. Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Habeas Corpus nº 596.603 - SP, de relatoria do i. Ministro Rogerio Schietti Cruz (item 21.4.: “Aos condenados que atualmente cumprem pena por crime de tráfico privilegiado, em que se reconhecem todas as circunstâncias como favoráveis, e aos que vierem a ser sancionados por tal ilicitude (mesmas circunstâncias fáticas), determinar que não se imponha - devendo haver pronta correção aos já sentenciados - o regime inicial fechado de cumprimento da pena”), imperioso, observado os parâmetros dispostos no artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal, o estabelecimento do regime aberto.

Descabida, de outro lado, implicando alteração de entendimento pessoal pretérito, a pretendida substituição da pena privativa de liberdade imposta por restritiva de direitos, simplesmente porque tal benefício, à vista das circunstâncias do caso e,

especialmente, da nocividade da conduta praticada, não se apresenta como medida suficiente e socialmente recomendável (artigo 44, inciso III, do Código Penal).

Como é sabido, o tráfico, independentemente de sua modalidade, envolve pessoas que disseminam um vício nefasto, movidas pela cobiça e pelo enriquecimento ilícito, constituindo, ainda, delito que fomenta a maior parte dos crimes patrimoniais, notadamente os mais graves, de forma a exigir, por parte das Autoridades constituídas, resposta penal firme e a altura do mal que causam à sociedade e famílias.

Nesse aspecto, por sua propriedade, transcrevo parte da decisão proferida pelo eminente Desembargador PINHEIRO FRANCO, ex Presidente de nossa honrada Corte de Justiça Bandeirante, nos autos da Revisão Criminal nº 0008791-07.2013.8.26.0000, julgada em 27 de março de 2014: “A atividade do traficante, indivíduo sem escrúpulos, é tão perniciosa para a sociedade, destruindo o cidadão e sua família para o exercício do comércio ilícito, que fica até mesmo difícil imaginar uma pena substitutiva para ser aplicada, se fosse caso. Ademais, condutas como a do acusado disseminam o vício, criando toda sorte de problemas, desde os mais óbvios, de saúde pública, até aqueles que constituem reflexo da atividade, vez que a prática do tráfico fomenta a ocorrência de diversos outros crimes graves, demandando uma enérgica e séria reação do Estado, até como fator profilático”.

O mesmo entendimento é adotado, atualmente, pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. REGIME INICIAL SEMIABERTO. QUANTIDADE, VARIEDADE E NOCIVIDADE DOS ENTORPECENTES. FIXAÇÃO DO REGIME INTERMEDIÁRIO JUSTIFICADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DO REQUISITO DE ORDEM OBJETIVA PREVISTO NO ART. 44, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL - CP. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A alteração do que restou consignado na instância ordinária, de maneira a reconhecer a hipótese de absolvição, demandaria o reexame das provas e fatos constantes dos autos, o que é inviável na instância especial. Incidente o verbete n. 7 da Súmula do STJ. 2. Firme o entendimento de que nos delitos previstos na Lei de Drogas, a fixação do regime prisional deve observar a regra imposta no art. 33, § 2º do Código Penal - CP em conjunto com o art. 42, da Lei n. 11.343/2006, que determina a consideração, preponderantemente, da natureza e quantidade da droga. 3. Incabível a substituição da pena corporal por restritivas de direito, nos termos do artigo 44, inc. III, do CP, devido à variedade, quantidade e natureza lesiva dos entorpecentes apreendidos (cocaína e crack). 4. Agravo regimental desprovido”.

(negritei)

(STJ - AgRg no AREsp 1674067/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/06/2020).

Na mesma toada, é o posicionamento atual de nossa E. Corte de Justiça Paulista, que abaixo transcrevo, com destaques:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS INFRINGENTES - TRÁFICO PRIVILEGIADO - ALEGA CONTRADIÇÃO DO ACÓRDÃO COM O JULGAMENTO DO HC Nº 596.603/SP, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - EMBARGOS ACOLHIDOS - FAZ-SE NECESSÁRIA A ADEQUAÇÃO DO JULGADO - CONFORME DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, FICOU VEDADA A APLICAÇÃO DE REGIME FECHADO AO TRÁFICO PRIVILEGIADO, QUANDO O RÉU É APENADO NO MÍNIMO LEGAL - SUBSISTE A IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE PENAS ALTERNATIVAS, DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO - EMBARGOS ACOLHIDOS PARA FIXAR REGIME ABERTO PARA OS EMBARGANTES, MANTENDO-SE, NO MAIS, O V. ACÓRDÃO.”

(Embargos de Declaração Criminal 1506211-61.2019.8.26.0050; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Relator (a): EUVALDO CHAIB; Data do Julgamento:

25/11/2020).

"EMBARGOS INFRINGENTES - Tráfico de drogas - Pretensão à fixação de regime inicial aberto e à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do voto vencido - Parcial acolhimento - Tráfico de drogas privilegiado - Natureza hedionda afastada - Substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos - Não cabimento - Benesse que não se mostra suficiente para reprovação e prevenção do crime - Regime inicial aberto - Possibilidade - Quantidade compatível à determinação do HC nº 596.603 do C. STJ - Embargos Infringentes parcialmente acolhidos."

(Embargos Infringentes e de Nulidade 0010198-32.2019.8.26.0196; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Relator (a): ROBERTO PORTO; Data do Julgamento: 24/11/2020).

"APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico de drogas - Autoria e materialidade delitiva comprovadas - Decisão condenatória que se impõe - Impossibilidade de absolvição - Inviável a desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/06 - Aplicação do redutor inserto no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06 - Regime aberto - Possibilidade - Determinação proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no HC nº 596.603/SP - Impossibilidade de substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos - Recurso ministerial parcialmente provido."

(Apelação Criminal 1500230-13.2019.8.26.0580; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Relator (a): RICARDO SALE JÚNIOR; Data do Julgamento: 11/11/2020).

b) Réu Alexssandro Ramos:

Em consonância com os artigos 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei nº 11.343/06, observo, à vista da Folha de Antecedentes e Certidão carreadas (fls. 347/349 e 350/351), que, além do acusado apresentar maus antecedentes, decorrente de recente condenação definitiva pelo crime de tráfico de drogas (Processo nº 1501344-90.2019.8.26.0481), apresenta culpabilidade acentuada (entendida como o grau de reprovabilidade de sua conduta), pois transportava consigo uma significativa carga de drogas ilícitas, que, além de proporcionar lucro vultuoso ao grupo criminoso articulador, elevando o seu poder econômico para a prática de outros crimes, fomenta a prática de outros delitos patrimoniais, notadamente os mais graves, causando, ainda, danos irreparáveis para diversas famílias, vítimas do vício nefasto proporcionado pela disseminação descontrolada de entorpecentes ilícitos.

Nesse raciocínio, fixo a pena base em patamar superior ao mínimo, aplicando-lhe, em relação ao crime de tráfico de drogas, a majoração de 1/4 (um quarto), ou seja, em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco reais) dias-multa, e, em relação ao crime de falsa identidade, optando pela pena segregativa, a majoração de 1/6 (um sexto), ou seja, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Por falta de elementos sobre a capacidade financeira do réu, o valor unitário do dia-multa deve ser fixado no mínimo legal.

Na segunda etapa da dosagem, registro que o réu confessou espontaneamente a prática do crime de tráfico de drogas (art. 65, III, "d", CP), razão pela qual atenuam-se as penas na proporção de 1/6 (um sexto), ou seja, em 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 520 (quinhentos e vinte) dias-multa.

Na terceira fase do cálculo, presente a causa de aumento capitulada no art. 40, inciso V da Lei nº 11.343/06, haja vista o crime de tráfico de drogas ter ocorrido entre os Estrados da Federação (Mato Grosso do Sul e São Paulo), elevam-se as penas em 1/6 (um sexto), passando-as para 06 (seis) anos e 27 (vinte e sete) dias de reclusão e 606 (seiscentos e seis) dias-multas, cabendo pontuar que não se aplica a

redução de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, pois, como já dito, o réu possuiu maus antecedentes, justamente por condenação pelo crime de tráfico de drogas.

Dessa forma, somadas, na forma do artigo 69 do Código Penal, as sanções impostas totalizam 06 (seis) anos e 27 (vinte e sete) dias de reclusão, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção e 606 (seiscentos e seis) dias-multas.

Fixo o regime fechado para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, conforme dispõe a Lei nº 8.072/90, artigo 2º, bem como, o artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, haja vista o quantum da sanção e os maus antecedentes ostentados.

Afora a natureza hedionda por equiparação do delito de tráfico, por não estarem preenchidos os requisitos subjetivo (maus antecedentes) e objetivo (quantum da sanção), não se aplicam a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a suspensão condicional da pena (artigos 44 e 77, ambos do Código Penal).

Por todo o exposto, sem mais delongas, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia (fls. 03/06), para:

a) CONDENAR a ré JEBECA BALVIN CALATAYUD, qualificada a fls. 41, nascida aos 29.03.2000, natural de Santa Cruz, Bolívia, filha de Rafael Balvin Condori e Gertudes Calatayud Colque, RG nº 42.602.141 (fls. 354), pela prática do crime descrito no artigo 33, "caput" da Lei 11.343/06, a cumprir a pena de reclusão de 03 (três) anos, 04 (quatro) meses e 25 (vinte e cinco) dias, em regime inicial aberto, e a pagar 340 (trezentos e quarenta) dias-multa, calculado o dia-multa no mínimo legal, a ser corrigido a partir da data dos fatos (07.02.2022).

b) CONDENAR o réu ALEXSSANDRO RAMOS, qualificado a fls. 137, nascido aos 01.04.1999, natural de Corumbá/MS, filho de Guillermo Pardo Ramos e Sandra Ramos, RG nº 75.001.251-1/SSP-SP, pela prática dos crimes descritos nos artigos 33, "caput" da Lei nº 11.343/06 e 307 do Código Penal, a cumprir a pena de reclusão de 06 (seis) anos e 27 (vinte e sete) dias, e de detenção de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias, em regime inicial fechado, e a pagar 606 (seiscentos e seis) dias-multas, calculado o dia-multa no mínimo legal, a ser corrigido a partir da data dos fatos (07.02.2022).

c) em acolhimento a manifestação externada pelas Defesas, com fundamento no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal, ABSOLVER os réus JEBECA BALVIN CALATAYUD e ALEXSSANDRO RAMOS, qualificados, respectivamente, a fls. 41 e 137, da prática do crime tipificado no artigo 35, caput, da Lei nº 11.343/06.

Ausentes, à luz do contexto dos autos, especialmente em razão da recente decisão do C. Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Habeas Corpus nº 596.603 - SP, os fundamentos para decretação da prisão preventiva, concedo à condenada Jebeca o direito de recorrer em liberdade. Expeça-se-lhe, imediatamente, alvará de soltura clausulado.

Diante da gravidade concreta da ação, eis que, como é sabido, o tráfico, independentemente de sua modalidade, envolve pessoas que disseminam um vício nefasto, movidas pela cobiça e pelo enriquecimento ilícito, constituindo, ainda, delito que fomenta a maior parte dos crimes patrimoniais, notadamente os mais graves, de forma a exigir, por parte das Autoridades constituídas, resposta penal firme e a altura do mal que causam à sociedade e famílias, somado, ainda, ao fato do acusado possuir recente condenação pelo crime de tráfico, inviável a concessão ao réu Alexssandro do direito de recorrer em liberdade, impondo-se imperiosa, pois, especialmente para garantia da ordem pública e diante do perigo que implica a sua liberdade, a manutenção da prisão preventiva ("ex vi" art. 312 do CPP).

Recomende-se o réu Alexssandro, pois, no estabelecimento prisional em que se encontra.

Tratando-se de pessoas desprovidas de recursos, condeno os réus ao pagamento das custas processuais, condicionando a cobrança à melhora de suas condições econômicas nos próximos cinco anos.

Por não vislumbrar correlação com a prática delitiva (fls. 167/172), autorizo, em favor dos respectivos proprietários, após o trânsito em julgado, a restituição dos aparelhos celulares apreendidos (Auto a fls. 22/23).

Para controle, consigno que a ré Jebeca é assistida por Defensor constituído (procuração a fls. 193) e o réu Alexssandro, por Defensor Público.

Diante da pendência do Habeas Corpus nº 2096071-64.2022.8.26.0000 (fls. 314/315), oficie-se ao E. Superior Tribunal de Justiça comunicando a presente sentença.

Em observância a Resolução 162/2012 do Conselho Nacional de Justiça (fls. 182), oficie-se ao Consulado Geral da Bolívia, ao Ministério das Relações Exteriores e ao Ministério da Justiça, comunicando a presente sentença.

Transitada em julgado, expeça-se guia de recolhimento, elabore-se cálculo atinente à pena de multa, façam-se as devidas anotações no Sistema Informatizado Oficial e comunicações ao IIRGD e à Justiça Eleitoral e, oportunamente, arquivem-se os autos.

Publique-se. Intimem-se. Comuniquem-se.

Presidente Prudente, 04 de setembro de 2022.

CIBELE CARRASCO RAINHO NOVO

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA